

1500302-83.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... com o réu Almir se destinava ao tráfico.

Não há nenhuma informação que o réu seja traficante no no local, nenhuma testemunha foi trazida aos autos que pudessem robustecer a acusação de tráfico de drogas, nem mesmo os policiais civis que prestaram depoimento, foram taxativos em afirmar que Almir realizada o tráfico de drogas no hotel ou pelas redondezas; a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500302-83.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500302-83.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALMIR LIMA ARRAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ALMIR LIMA ARRAIS (vulgo "Cowboy" e "Almirzinho"), qualificado à fl. 09, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de abril de 2022, por volta das 15h50min, na Avenida Brasil, nº 1.201, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo e guardava droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em: (i) 05 (cinco) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,3g (três decigramas - lacre nº 0026957); e (ii) 04 (quatro) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,53g (cinquenta e três centigramas - lacre nº 0026958), conforme boletim de ocorrência de fls. 13/17, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação provisório de fls. 25/27, fotografias

de fls. 51/53, exame químico-toxicológico definitivo às fls. 153/155 e laudo pericial dos objetos apreendidos às fls. 149/152. 2. Consta dos inclusos autos, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários competentes para executá-la. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de droga acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a trazê-las consigo pela via pública, bem como guardar porções da mesma substância entorpecente no quarto de hotel onde estava hospedado, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Recentemente, policiais civis realizaram diligências prévias a fim de checarem a veracidade da denúncia anônima que apontava a prática de tráfico de drogas no hotel denominado Stars e confirmaram que havia movimentação típica de traficância de drogas neste local. O traficante entrava e saía constantemente do aludido hotel, às vezes se deslocava à rua de trás e à esquina do estabelecimento, e com frequência entregava algo para terceiros. Colaboradores anônimos informaram aos policiais que o traficante se tratava de "Almir", vulgo "Cowboy" ou "Almirzinho", e que ele recebia objetos em troca de droga e usuários comumente deixavam veículos na guarda de ALMIR até lhe pagarem o dinheiro equivalente à droga vendida. Na data dos fatos, a equipe policial abordou ALMIR na porta de entrada do hotel Stars. Em revista pessoal, localizaram, no bolso do short do denunciado, cinco pequenas pedras de crack e uma nota de R\$ 5,00 (cinco reais). No quarto em que o imputado estava hospedado encontraram, dentro do colchão da cama, quatro pedras de crack embaladas em saco plástico e, na rack do mesmo cômodo, foram localizadas duas facas com resquícios de crack. Na capinha do aparelho de telefone celular do imputado havia uma gilete também com resquício de crack (fls. 149/152). Ademais, em cima do guarda-roupas do denunciado foi localizado um simulacro de arma preto. Durante as buscas, o denunciado tentou retirar os policiais civis do quarto de hotel, ocasião em que empurrou o policial Andrews Markus Bratfisch em direção à porta do cômodo. Algemado, ALMIR ameaçou a equipe policial dizendo-lhe: "isso não ficará assim, eu vou atrás, eu não vou matar ninguém, mas vou usar todo dinheiro para acabar com sua carreira". Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somada à quantidade de substância entorpecente apreendida com o denunciado e no quarto em que estava hospedado, já embalada e fracionada para facilitar a comercialização, adquirida de pessoa até o momento não identificada, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação o réu ofertou defesa preliminar (fls. 181/182), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 187) e o despacho de fls. 188/192, de 31 de maio de 2022, recebeu a denúncia e determinou o recolhimento da prova, que se deu com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça, (fls. 322/323), pediu a procedência da ação penal para condenar o réu nos termos da pela acusatória inicial. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 329/361), em resumo, pleiteia a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, previsto o artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, requer a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento deste juízo, que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea na segunda fase, faz jus ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como regime aberto para cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante

provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados aos réus encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21; pelo laudo de constatação preliminar de droga de fls. 225/227; pelo laudo pericial de fls. 143/148; pelo laudo pericial de objetos de fls. 149/152; pelo laudo de exame químico toxicológico de entorpecente de fls. 153/155 que atestou - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0026957) Descrição: 1 (um) porão de material sólido petrificado bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 1,88 grama(s) - 1 grama e oitenta e oito centigramas. Massa Líquida: 0,3 grama(s) - três decigramas. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0026958) Descrição: 4 (quatro) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido petrificado bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 2,33 grama(s) - dois gramas e trinta e três centigramas. Massa Líquida: 0,53 grama(s) - cinquenta e três centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), pelo laudo pericial do telefone celular de fls. 233/238; além da prova oral robusta carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha Andrews Markus Bratifisch, sob o crivo do contraditório declarou que apenas participou da investigação na parte operacional de responsabilidade do investigador Valdir, e entre outras infrações, receberam denúncias de tráfico de drogas, e davam conta de pessoa com nome de Almir, vulgo "cowboy", que estava comercializando entorpecentes tipo crack, nas proximidades do Hotel Star do atrás do Portal do Oeste e no momento da batida no quarto do réu, não estava, mas fazia outras diligências em outros quartos onde havia outras situações a serem investigadas, quando ouviu a abordagem na parte interna do hotel, pois ouviu vozes alteradas e que tinham encontrado crack no bolso da sua bermuda. O proprietário do hotel usa diariamente e o funcionário não tinha acesso para limpeza e não sabia o que havia no quarto. Indagado disse que não havia nada de ilícito, e encontraram em cima do guarda roupas, um simulacro de arma de fogo, dentro de um livro, cheques em branco de terceiros e nesse momento ele começou a ficar agitado e foram algema-lo, quando Almir lhe empurrou e o algemaram. Ele disse que tinha policiais familiares, mas não iria lhe matar, mas faria de tudo para o prejudicar. Afirma que não conhece o réu, sabe que ele mora fora da cidade e por isso que ele estava hospedado no hotel. No colchão que usava no quarto, estava rasgado, e encontraram três porções de crack embaladas, diferentes da que encontraram em sua bermuda, pois estas não estavam embaladas, e quanto aos cheques, disse não lhe pertencer. Diante disso, da denúncia, encontrada droga no bolso e no colchão, ele foi conduzido a Delegacia. Afirma que ao indaga-lo sobre as drogas, disse que era somente para seu uso. Também afirma que foram encontradas chaves de veículo que corroboram com a investigação feita por Valdir, que deixavam os veículos como forma de pagamento da aquisição de drogas. No apartamento quando chegou, perguntou o que havia, pois havia gritos, e não tem ideia do que pode acontecer, e mesmo assim ele não lhe fez nenhum gesto. Após a localização das facas com resquícios, já evidenciava que desfigurava a alegação de uso do réu e parecia que utilizava o quarto para outra situação, quando ele se alterou e lhe empurrou, dizendo sai daqui e por isso o algemou. O simulacro que encontraram, de longe assusta, mas ao ver mais de perto vê que não é. Confirma que Almir acompanhou nos momentos iniciais, mas depois que encontraram as facas e as folhas de cheques, ele ficou irritado e por isso algemado e levado para a viatura, sendo então solicitada a presença do proprietário do hotel. No momento que encontraram a droga no colchão ele não estava presente, somente o proprietário, este já estava no corredor do hotel, solicitando que acompanhasse, porém, no início se mostrou um pouco reticente, mas disseram a ele que o imóvel lhe pertencia e que precisava acompanhar as buscas. Dentro do quarto não se recorda se havia lata ou cachimbo no quarto, nem balança e material para embalar, porque também saiu do quarto após o réu também ter sido algemado, porém, afirma que localizou a droga, retirou e ficou na porta, deixando os demais investigadores terminarem outras buscas. Afirma que o quarto era pequeno,

bagunçado, não é organizado, mas não tem como afirmar que era utilizado para usar droga e não se lembra de ter encontrado cachimbo ou outro petrecho para usar droga. Acredita que no momento da abordagem o réu estaria entrando no hotel, porém, os demais policiais poderão confirmar essa situação. Afirma que em relação a outros usuários, o próprio hotel é utilizado por outros usuários, por pessoas que moram na rua, que se prostituem, mas afirma que o investigado é usuário, não há como saber, também que ele não é usuário. Quanto as agressões foram no momento do nervosismo, mas relatam os fatos, para que não haja divergências, mas afirma ter sido empurrado pelo réu no momento da algemação, talvez num momento de estresse. O réu na Delegacia disse que era de Santo Anastácio, e que o nervosismo foi somente na hora do flagrante, que é normal. Acredita que o réu lhe empurrou apenas naquele momento de nervosismo, mas há necessidade de relatar tais agressões, pois quando foi para próximo ao acusado ele fez o gesto para empurra-lo e afasta-lo, e aproveitou a mão dele que estava esticada e fez a algemação. Ele não impediu as buscas no quarto, no entanto, o quarto possui 4 por 3 metros, e havia uma estante baixa onde foi localizado os cheques no meio de um livro que folheou, e quando apresentou os cheques, ele fez essa menção de tentar se desvencilhar e fez a algemação e ele resistiu a algemação, e afirma que ele não impediu qualquer buscas, mas apenas de ser algemado, já que ele acabou esticando as mãos e encostando em seu corpo, pois isso o algemou. Se ele não fizesse isso não o algemaria, estava cordial o tratamento entre ele e a polícia. Mesmo tendo ele encostado em seu corpo, não chegou a lhe empurrar para trás ou perder o equilíbrio.

A testemunha Valdir de Jesus Barreto, sob o crivo do contraditório declarou que receberam uma denúncia de que havia tráfico de drogas nas redondezas do hotel, ficando de campana por alguns dias e perceberam que havia movimentação muito grande de pessoas, usuários entrando e saindo do hotel, conversando um com outro, cumprimentando com a mão, dando perceber que passavam objetos um para o outro, e uma das pessoas que deu a impressão de pratica esse ato era o Almir, até então era desconhecida a pessoa, todavia, depois de conversas informais pela redondeza, identificaram que uma pessoa que estava hospedada há muito tempo no hotel, saía muito para a rua, ia para o fundo do hotel, então resolveram ingressar no hotel para fazer diligências, e nada foi encontrada, porém, quando saíam do hotel se depararam com o Almir, e em conversa com ele disse que estava hospedado no hotel, e no seu bolso foi localizada algumas pedrinhas de crack. De início tentou desvencilhar, então encontraram uma chave, e segundo informações, usuários diziam que ele estava hospedado nos fundos. Foram até o seu quarto para uma busca, onde localizaram alguma faca, alguma coisa com resquícios de drogas, algumas chaves de veículos, folhas de cheques, e em cima do guarda roupas foi localizado um simulacro, e começaram a questiona-lo. Diante das denúncias de que ele guardava entorpecentes, pegava objetos na troca, e segurava carros para posteriormente pagar os entorpecentes, quando ele começou a ficar nervoso, e questionado, disse que é usuário, e certo momento, se levantou e teve que ser algemado por policiais. No colchão também foi encontrado mais uma porção de droga. Conduziram-no até a Delegacia onde ele confessou que é usuário e a droga era para ser compartilhada com pessoa de nome Rosa. Parece que Rosa foi localizada no dia seguinte e apresentada na Delegacia, e ela comentou que havia adquirido algum entorpecente com Almir. Salvo engano encontraram 3 chaves, e salvo engano, ele disse que era de veículos que lhe pertenciam ou era da família, e questionado onde estariam esses veículos, ele disse que estava trabalhando há pouco tempo com retroescavadeira, e perguntou onde ele trabalhava, onde estava os veículos, mas ele se negou a informar. Confirma que se deparou com o Almir entrando no hotel, e com ele foi localizado apenas algumas pedras de crack e R\$ 5,00 em dinheiro. Na busca no quarto, não aparentava que utilizava para usar droga, porém, o dono do hotel disse que sentia um forte odor vindo do quarto e que ele não deixava ninguém entrar no quarto para fazer limpeza ou verificar. Afirma que o proprietário disse que do quarto dele vinha um forte cheiro. Ele não resistiu a abordagem e dizia o tempo todo que era usuário de drogas, e tentava se desvencilhar, dizendo que não estaria hospedado ali, mas posteriormente acabou confessando, vista que encontraram chaves com ele. Sempre dizia que era usuário e a droga era para compartilhar. Somente no quarto, ficou

nervoso durante a abordagem, mas depois se acalmou. Afirma que foi visto no local, suspeito, e uma das pessoas que saía e entravam era o Almir, e tem outras pessoas sendo investigadas no local. Disse que conforme informaram, ele estava hospedado no hotel havia 30 dias.

A testemunha Luis Henrique Pancotti, sob o crivo do contraditório declarou que o investigador Valdir pediu para lhe dar apoio na diligência e no local, Almir entrava no hotel quando foi abordado e com ele foi localizado entorpecente, crack e R\$ 5,00 em dinheiro no bolso dele, e no quarto dele foi localizado facas e gilete com resquícios de drogas, chaves de veículos e três folhas de cheques em nome de terceiros, durante a revista também localizaram mais drogas no quarto. Indagado, Almir disse que era usuário depois ficou alterado e teve que ser algemado para ser contido, e posteriormente encaminhado a Delegacia de Polícia. Na primeira abordagem ele não tentou reagir, ficou assustado e negou que tivesse hospedado no hotel, depois que foi conduzido ao quarto e localizadas as folhas de cheque, quando ele ficou bastante alterado. Fez revista no quarto que ele estava hospedado, não se recorda se foi localizado petrechos para utilizar droga, mas despertou bastante curiosidade as folhas de cheque e o simulacro. Afirma que no local há usuários e vendedores, todos se misturam, e não se recorda de localizar nenhum usuário que conhecem.

A testemunha Roseli Lino de Souza, declarou que é apenas conhecido do hotel onde mora, que ele também morava lá. Sobre os fatos disse que não tem conhecido dos fatos e não os viu, pois não estava no local. Ainda mora no hotel. Não sabe quanto tempo Almir morava no hotel. Disse que nunca adquiriu droga do Almir, são usuários, as vezes ele lhe dava um trago, as vezes lhe dava um trago quando tinha. Não viu nada estranho de que ele vendia drogas no local.

A testemunha Roberto Vieira, sob o crivo do contraditório declarou que não estava presente no momento da diligência, quando seu filho lhe telefonou e relatou o que estava ocorrendo. Quando chegou não viu o encontro da droga, não viu Almir sendo abordado. Acredita que Almir estava hospedado há aproximadamente 15 dias. Chegou a perguntar ao réu o que ele fazia, disse que trabalhava de tratorista, em sítio ou fazenda da família. Afirma que ele saía de dia e de noite. Não viu ele na linha férrea. Confirma que foi até o quarto onde já estavam os policiais, conversou com os investigadores, levaram-no até o quarto do Almir, mas não viu Almir alterado, disseram que ficou alterado antes de chegar, mas não viu. Afirma que percebeu o cheiro estranho, ficou desconfiado de coisa errada, e ele confirmou que usava, e pediu para ele procurar outro local para ficar, mas nos últimos dias, ficou sabendo, mas não poderia tira-lo, pois ele estava pagando. Não é deixado nenhum pertence de hospedes nos quartos.

Em seu interrogatório, Almir Lima Arraes, disse que já foi preso e cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que no dia dos fatos, desceu na linha e pegou R\$ 20,00 de crack na linha, já tinha pegado R\$ 10,00, e como acabou, retornou na linha para buscar mais drogas e quando voltou para o Hotel, o policial lhe abordou e perguntou o que estava fazendo ali, tendo dito a ele que estava procurando um quarto para se hospedar. O policial começou a fazer buscar, encontrou os pedaços de crack no seu bolso do short, e encontrou os pedaços de crack, em pequenos pedaços, e mais R\$ 5,00, e perguntou novamente e se estava hospedado, mas disse que não e que iria alugar um quarto para ficar e pode usar. Foi-lhe dado voz de prisão e então confirmou que realmente estava hospedado naquele hotel. Disse que mentiu porque ficou com medo, que estava sob efeito de drogas. Levaram-no no quarto e iniciaram as buscas, não encontraram nada no quarto. O agente Andrews encontrou um livro, começou a folhear e encontrou três folhas de cheque em branco e sem ele perguntar nada, falou que não lhe pertencia. Com isso o agente Andrews disse que não me perguntou nada, cala a sua boca e arremessou o livro em seu rosto, e diante disso, perguntou se ele era acostumado a bater em nória, mas que não um qualquer não, pois tinha família, que era homem igual a ele, que era para ter respeito para ser respeitado, independente da "cor da calça" e disse a ele para ter respeito, e que era uma vez só que Andrews iria bater nele. Não empurrou o policial Andrews. Afirma que havia duas faquinhas de serra, que usava para raspar o fundo da lata para usar o restinho que ficava no fundo. Também havia um simulacro, que havia um

monte de luzinhas, era brinquedo do seu filho. Afirma que mora em Mirante do Paranapanema, e fazia um serviço entre Alvares Machado e Alfredo Marcondes, no bairro da represa, próximo a cidade de Presidente Bernardes. Fazia serviço de terraplanagem para o Sr. Marcos, e não havia registro, era diária, recebia a cada 15 dias. Quanto as chaves do carro, eram três, uma chave de uma Santa Fé de sua esposa, outra da sua camionete e uma de um Crossfox que estava dentro da sua bolsa, e era uma chave reserva. Quando houve essa desavença com o Andrews, quando o Naim chegou perto e disse "chega...chega", e o levaram para fora, e ainda dizia para o Andrews que o que ele fez não era certo, então ele pediu para levarem-no para a viatura, mas contestou e argumentou dizendo "como vocês vão fazer buscas sem a minha presença, e se encontrar outras coisas ilícita, é minha, o que o Senhor encontrou comigo é meu, sou homem de assumir minhas coisas". Ele disse que o dono iria acompanhar, mas contestou novamente dizendo que como ele iria acompanhar, se estava hospedado há 20 dias, nem o conhecia direito, é um lugar onde está residindo. Mesmo assim, o levaram para a Delegacia e depois chegaram após as 22 horas dizendo que encontraram droga, armas e mais outras coisa e lhe disseram que estava preso em flagrante. Nunca respondeu processo por tráfico, apenas por furto e estelionato.

Entretanto, dos relatos da prova oral produzida, restou dúvida insuperável nos autos que a droga encontrada com o réu Almir se destinava ao tráfico. Não há nenhuma informação que o réu seja traficante no local, nenhuma testemunha foi trazida aos autos que pudessem robustecer a acusação de tráfico de drogas, nem mesmo os policiais civis que prestaram depoimento, foram taxativos em afirmar que Almir realizou o tráfico de drogas no hotel ou pelas redondezas; a quantidade de droga não é de forma expressiva a demonstrar por si só a ocorrência do tráfico pelo réu, nem mesmo os demais objetos são suficientes para dar guarida a palavra dos policiais.

Embora tenham localizado um simulacro, ao que parece, é apenas um brinquedo de criança, já que ao ser acionado acende uma luzinha, portanto, de forma alguma serve para intimidar um praticar qualquer outro crime. Há também o encontro de folhas de cheque dentro de livros, que sequer foi apurado a quem pertencia o livro, se ao hotel ou ao réu, ou a outro hospede daquele estabelecimento, e ao que parece, serve de local para encontros de prostitutas e usuários de drogas, de forma que tais indícios não podem ser interpretados contra o réu, apenas, já que se trata de local com intensa movimentação, não há qualquer prova de que pertenciam ao réu, mesmo que encontrados em seu quarto.

Da análise minuciosa das provas colhidas verifica-se que, no presente caso, não há suporte fático suficientemente seguro para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas ao réu.

Nem mesmo as testemunhas que vieram a Juízo foram capazes de afirmar que a droga encontrada com o réu era destinada ao tráfico de drogas, embora trazer consigo ou transportar seja núcleos verbais do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se mostrou robusta a prova de que a droga se destina a venda ou comercialização.

A testemunha Roseli, que conhece o réu, afirmou que ambos fornecem um ao outro, mas isso não é sequer indício de tráfico entre os dois, mas apenas demonstra uma certa parceria, quando um tem, fornece ao outro que não tem, não é indicativo de traficância.

Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu: "Tráfico de drogas - Fragilidade da prova referente à destinação do entorpecente ao comércio - Desclassificação para posse de drogas em razão da comprovação da apreensão do entorpecente em poder do apelante - Inteligência do art. 28, da Lei nº 11.343 - Recurso da Defesa parcialmente provido com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva" (Apelação criminal nº. 0008679-51.2009, Salto, rel. Alexandre Almeida, j. 13.4.2011).

"E, ainda que tivesse o apelante admitido a propriedade da droga, na fase judicial, afirmou que se destinava a consumo próprio, negando o tráfico, o que há de ser recepcionado, pois, em realidade, nenhuma prova se fez em sentido contrário, ou seja, que houvesse o intuito de entrega ou fornecimento a terceiros, mormente se

confrontada a conduta assumida com os elementos de convicção trazidos aos autos, não havendo possibilidade, assim, de manter-se, o decreto condenatório, com fulcro no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mesmo porque, ante a gravidade dos fatos deduzidos na inicial e considerado que a resposta penal para o delito imputado é por demais severa, se exige, como manifesto, prova límpida e estreme de dúvida, em relação à autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente; de rigor., portanto, operar a desclassificação" (Apelação Criminal nº 990.09.174232-5, São Paulo, rel. Antonio Manssur, j. 15.12.2010)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06)- POSSIBILIDADE - AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para consumo pessoal quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - APL: 00021751520168260322 SP 0002175-15.2016.8.26.0322, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 08/06/2017, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2017).

A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência maiores elementos que posso imputar ao réu a prática do comércio espúrio naquele local, e a falta de abordagem de suposto adquirente são indicativos de que a droga era para consumo próprio.

A conduta do réu não se materializou para confirmar que a droga que foi encontrada com ele teria destinação a usuários daquela região, visto que o local é bastante frequentado por muitos usuários e traficantes, mas, o modo e a quantidade que foi encontrada, aliada a ausência de indicativos de que a droga era para o tráfico, impossível um decreto condenatório nesse sentido.

Ausente a prova incontestada do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso próprio. Não é suficiente a probabilidade do cometimento do delito. A dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas se revolve em favor do réu.

A subsistência do caráter criminoso da conduta porte de droga para consumo pessoal se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas.

A lei não pune, contudo, o consumo da droga (se o fizesse o tipo seria inconstitucional); incrimina-se, tão somente, o ato de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo (para consumo pessoal) drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E é nessas situações que o comportamento do agente vulnera o bem tutelado na norma incriminadora, tendo em conta as propriedades maléficas da droga e a potencial disseminação desses malefícios na sociedade.

O artigo 28, da Lei 11.343/06, cuida de infração de mera conduta, não se fazendo mister nenhum perigo concreto ao bem jurídico.

Já que trata de mera infração "sui generis", não sendo a prisão a pena cominada, pode-se transigir com as exigências emanadas do princípio da ofensividade (lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico).

Tal como ressaltado, a coibição legal do uso de drogas não se destina somente ao usuário, vai além, impede a proliferação dos malefícios das substâncias entorpecentes para a coletividade e para a saúde pública, sendo típica a conduta.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da natureza jurídica da conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo, por conseguinte, a constitucionalidade da criminalidade do uso de entorpecente, confira-se:

"POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL: (ART. 28 DA L. 11.343/06 - NOVA LEI DE DROGAS): NATUREZA JURÍDICA DE CRIME - 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que Lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela Lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L.11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de

drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L.11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao USO da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95(art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: Consumação, à vista do art. 30 da L.11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE-QO 430105 -RJ - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 27.04.2007).

Não se pode olvidar que o legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006, optou por abrandar as sanções cominadas ao usuário de drogas, afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade e prevendo somente as sanções de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme os incisos do artigo 28, de molde a possibilitar a sua recuperação. Vale dizer, a intenção do legislador foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, assim, alertá-lo sobre o risco de sua conduta para a própria saúde, além de evitar a reiteração do delito.

Nesse contexto, em razão da política criminal adotada pela Lei nº 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas.

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Vale dizer, o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou do próprio indivíduo.

Assim, não se pode aplicar o princípio da insignificância ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sobretudo ao caso dos autos, sob pena de se tornar sem valia o dispositivo legal em comento e de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Confira-se:

"Posse de entorpecente para uso. Artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. Réu surpreendido por policiais no momento em que adquiria uma pedra de "crack". Confissão do acusado respaldada pelos relatos dos policiais responsáveis pela diligência. Prova hábil. Condenação de rigor. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Pena de prestação de serviços à comunidade adequada. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar" (TJ/SP; Apelação 0021406-15.2011.8.26.0577; Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/05/2013).

Nesses termos, passo à dosimetria da medida.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena em advertência sobre os efeitos das drogas.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a conduta inicialmente imputada ao réu para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e dessa forma, CONDENO o réu ALMIR LIMA ARRAIS, devidamente qualificado nos autos, a cumprir a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, conforme dispõe o artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.



Após o trânsito em julgado será designada audiência de advertência. Restitua, incontinentemente, ao réu Almir, o dinheiro e o aparelho celular apreendido nos autos, pois o laudo constata que é o réu que possui perfil para configuração de aplicativos, em redes sociais e no aplicativo whatsapp, todavia, as chaves de veículos, embora ele afirme lhe pertencer, não houve comprovação da propriedade dos veículos como ele próprio disse em seu interrogatório. Oficie-se a Autoridade Policial para restituição do celular e do dinheiro, mediante termo nos autos. Condene o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA